

1500221-29.2022.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: João Carlos Germano

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... tinha em depósito, para fins de tráfico, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado pela acusação, na data dos fatos, no primeiro endereço mencionado, o réu tinha consigo, para fins de tráfico, no bolso traseiro da bermuda que vestia, 5 porções de cocaína acondicionadas em pequenos tubos plásticos do tipo "eppendorf". Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

3ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Fórum Criminal

CEP: 12020-070 - Taubaté - SP

Telefone: (12) 2124-9113 - E-mail: taubate3cr@tjsp.jus.br

1500221-29.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500221-29.2022.8.26.0618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcos Paulo Fernandes

Réu Preso

Juiz de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

Marcos Paulo Fernandes foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das 10h30min, na Rua Antônio Ferreira da Silva, nas proximidades do "Bar do Dedé", Bairro Areão, nesta cidade e comarca de Taubaté, trazia consigo e, na Rua José Pereira da Silva, nº 476, Parque Sabará, nesta cidade e comarca de Taubaté, tinha em depósito, para fins de tráfico, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado pela acusação, na data dos fatos, no primeiro endereço mencionado, o réu tinha consigo, para fins de tráfico, no bolso traseiro da bermuda que vestia, 5 porções de cocaína acondicionadas em pequenos tubos plásticos do tipo "eppendorf". Em sua residência, no segundo endereço, dentro de um filtro de barro localizado na cozinha do imóvel, outras 65 porções da mesma droga.

Na oportunidade, ao ser avistado no primeiro local por policiais militares,

demonstrou nervosismo incomum, o que fez com que fosse abordado. Durante abordagem, a droga que trazia consigo, para a venda, foi apreendida. Em continuação à diligência, os policiais militares se dirigiram à residência do réu onde, após ser franqueada a entrada, encontraram o restante da droga.

A droga foi regularmente apreendida e submetida a exame de constatação prévia.

Com o réu foi encontrado, ainda, a quantia de R\$ 77,00 e, em sua residência, outros R\$ 100,00, produto da venda anterior de drogas.

Busca, assim, a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi recebida às fls. 75/77.

Citado pessoalmente (fls. 84), o réu apresentou resposta escrita à acusação às fls. 92.

Designou-se audiência, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas Caetano Ribeiro de Oliveira, Edmilson Eufrásio Damasceno e Claudia Augusta Gomes de Almeida.

Em nova audiência procedeu-se ao interrogatório do réu, sendo as alegações finais convertidas em memoriais.

O Ministério Público postulou a procedência do pedido, alegando que a autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas pelas provas existentes nos autos. Manifestou que a versão apresentada pelo réu é mendaz, considerando o conjunto probatório dos autos. Em depoimento, os policiais narraram a localização de 5 porções de cocaína acondicionadas em pequenos tubos, dentro da bermuda do réu. Enfatizou que não há qualquer razão para desconsiderar as palavras das agentes de segurança ou questionar os seus relatos. Inclusive, o réu não conhecia os policiais militares. Destacou que, embora ele tenha confessado informalmente e alterado sua versão no auto de prisão em flagrante, concedeu a autorização para que fossem realizadas buscas em sua residência. Ademais, anotou que não há nenhuma prova que pudesse confirmar a versão exculpatória, uma vez que a defesa desistiu da oitiva da testemunha arrolada na defesa prévia e sua genitora, ouvida como informante, não presenciou os fatos. Outrossim, defendeu que, apesar do réu não ter sido efetivamente surpreendido comercializando drogas, é certo que para a configuração do delito de tráfico não é necessária prova da mercancia, tratando-se de crime de conteúdo múltiplo ou variado. Salientou que o réu está sendo processado pela prática de outro delito de tráfico de drogas, oportunidade em que confessou a prática delitativa. Discorreu que o fato de o réu assumir sua condição de viciado não exclui a possibilidade de também ser traficante, porque muitas vezes essa conduta é praticada por usuários para sustentar o vício. Por todas essas circunstâncias, requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Na dosimetria, vislumbrou a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida e a natureza do entorpecente, o que demonstra que ele não era pequeno traficante, pleiteando a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Na terceira fase de dosimetria da pena, afiançou ser incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pelo mesmo motivo, fato que demonstrou que o réu estava envolvido de forma habitual na atividade criminosa. Mencionou que o réu praticou o crime durante gozo do benefício de liberdade provisória que lhe foi concedido após ter sido preso em flagrante delito pela prática de crime da mesma natureza. Para o regime de cumprimento, solicitou que seja aplicado o fechado, sendo este o único compatível com a conduta praticada pelo réu e sua personalidade voltada à prática de crimes.

A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência do pedido. Preliminarmente,

mencionou que, por decisão do Supremo Tribunal Federal, a fundada suspeita, para motivar a busca pessoal, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. No caso concreto, diante da ausência de elementos dessa natureza, afiançou que a busca pessoal e a domiciliar não poderiam ter sido realizadas, não havendo qualquer elemento concreto que justificasse a invasiva medida e não se tornando válida pelo fato de que foram encontrados entorpecentes em poder do réu. Nesse sentido, anotou que os policiais apresentaram depoimento divergente, sendo que um deles relatou que a abordagem teria ocorrido em razão do desvio de olhar do réu e outro que teria se originado pelo fato de ter ocorrido a mudança de direção em seu caminhar. Em consonância, discorreu que o ingresso na residência do réu ocorreu sem a autorização do próprio, embora tenham alegado que a possuíam. Defendeu, aliás, que, ainda que tenha sido dada alguma autorização, ela teria sido fornecida em razão de coação, sem qualquer maior esclarecimento e em total vulnerabilidade. Nesse cenário, concluiu que o auto de apreensão e os laudos periciais são oriundos de uma ilicitude e, por isso, imprestáveis para a formação do convencimento judicial. Dessa forma, requereu o desentranhamento de referidos documentos dos autos, com consequente afastamento da materialidade do delito e absolvição do réu. No mérito, postulou a absolvição do réu por ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ressaltando que os policiais, em juízo, tentaram justificar suas falhas e divergiram em pontos cruciais da abordagem. Assim, manifestou que a versão dos policiais não foi segura e ainda demonstrou falhas que comprometem a licitude do feito e a idoneidade do acervo. A versão apresentada pelo réu, todavia, mostra-se crível. Caso o entendimento não seja este, em eventual condenação, pleiteou a desclassificação da conduta de tráfico para a de porte para uso pessoal. Salientou que, com base na versão oferecida pelo réu e nas dúvidas trazidas acerca da licitude da busca domiciliar, o que se tem de incontroverso é a posse de um pino de cocaína para uso pessoal. No caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, postulou a fixação da pena-base no mínimo legal, considerando que a quantidade de drogas não se revelou discrepante em relação a casos semelhantes. Destacou que o réu é primário e não ostenta antecedentes criminais. Na segunda fase, solicitou que seja reconhecida a confissão extrajudicial, uma vez que permitiu a localização das drogas apreendidas. Por fim, pediu que seja aplicado o redutor previsto no § 4º do artigo 33, da Lei de Drogas, bem como o regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois preenchidos os requisitos legais.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, por meio da qual o Ministério Público requereu a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Não há questões preliminares a se enfrentar. As condições da ação estão presentes, assim como os pressupostos processuais, o que rende ensejo à apreciação do mérito.

É o caso de acolhimento do pedido condenatório.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), termo de depoimento (fls. 2/3), termo de interrogatório (fls. 4), boletim de ocorrência (fls. 5/6), auto de qualificação, vida pregressa e BIC (fls. 9), auto de exibição e apreensão (fls. 10), auto de constatação preliminar (fls. 12/17), laudo pericial (fls. 124/126) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Com relação à autoria, melhor sorte não assiste o acusado, em razão da robusta prova atribuindo a ele a prática do crime de tráfico de drogas.

A testemunha Edmilson Eufrásio Damasceno, ouvida em juízo, aduziu que no dia do ocorrido estava em patrulhamento de rotina pelo bairro, conhecido pelo tráfico de drogas quando avistaram o réu, com uma conduta duvidosa e desviando o olhar. Comentou que o abordaram e localizaram cinco "eppendorfs" com cocaína e R\$ 77,00 em espécie. Relatou que o réu confirmou que comercializava droga no local. Complementou que o réu é conhecido, que já fora abordado outras vezes, contudo, sem droga. Afiançou que o réu os levou até seu imóvel, franqueou a entrada e acompanhou a vistoria, sendo encontrado dentro de um filtro de barro de água na cozinha, mais 65 eppendorfs de cocaína e R\$ 100,00 em espécie. Finalizou dizendo que não realizou uma prévia averiguação do que ocorria no local dos fatos e não avistou ninguém perto do réu no momento da abordagem.

A testemunha Caetano Ribeiro de Oliveira, ouvida em juízo, aduziu que no dia da ocorrência estava realizando um patrulhamento no bairro perto do bairro Sabará, quando avistaram um indivíduo com atitudes suspeitas e mudando de direção. Relatou que realizou a abordagem e a revista quando encontraram cinco eppendorfs com cocaína e R\$ 77,00 em espécie. O réu confessou que estava realizando o tráfico de drogas no local e havia mais droga em sua residência. Informou que realizou a diligência até o imóvel, acompanhado pelo réu, quando localizaram mais 65 eppendorfs com cocaína e R\$ 100,00 em espécie, dentro de um filtro de barro na cozinha. Comentou que só havia o réu no imóvel. Finalizou que ao término da vistoria no imóvel do réu foram até a casa da vizinha. Afirmou que não houve a necessidade da oitiva de mais testemunhas.

A testemunha Cláudia Augusta Gomes de Almeida, ouvida em juízo, afirmou que é genitora do réu e que este é usuário de entorpecentes. Relatou que ela que faz a limpeza de sua residência e nunca avistou nenhum entorpecente. Afiançou que no dia do ocorrido o réu estava na casa de sua mãe. Finalizou dizendo que ao conversar com os vizinhos sobre o ocorrido apenas ficou sabendo que ele ficou do lado de fora enquanto ocorria a vistoria, pois somente os policiais entraram no local.

O réu Marcos Paulo Fernandes, interrogado em juízo, asseverou que tem conhecimento da acusação e negou que seja verdadeira. Narrou que estava na rua de trás de sua casa, consumindo entorpecentes, quando a viatura encostou. Afirmou que não demonstrou nervosismo. Em seguida, foi abordado e informou seu endereço. Como consequência, eles se deslocaram até sua residência. No local, eles primeiramente entraram na casa de sua vizinha. Logo após, eles pegaram sua chave e entraram em sua residência, impedindo que saísse da viatura. No momento, pediu que uma vizinha fosse acompanhá-los, todavia, não deixaram que ela entrasse. Cerca de 2 minutos depois, eles saíram e alegaram ter encontrado entorpecentes no imóvel, conduzindo-o à Delegacia. Negou conhecimento sobre a droga. Informou que mora com os tios e eles não admitem esse tipo de coisa. Não viu os entorpecentes no local. Citou que já foi abordado por aqueles policiais, mas nunca com nada ilícito. Disse ser solteiro, não tem filhos e morava com os tios; desempregado; era usuário de cocaína, mas não faz mais uso da droga; tem outro processo por tráfico de drogas.

Bem provadas a autoria e a materialidade.

Dispõe o artigo 33, caput, da Lei de Drogas:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:"

Verifica-se que a conduta do réu encontra subsunção em diversos verbos do núcleo do tipo, notadamente trazer consigo e ter em depósito drogas, resultando, assim,

configurada a traficância.

A própria prisão em flagrante do réu deu conta de que trazia consigo 5 pinos contendo cocaína e, em sua casa, outros 65, quantidade que demonstra não outra coisa que não seja a destinação para o comércio ilícito.

Anoto que os depoimentos prestados pelos policiais foram coesos e harmônicos, inclusive reproduzindo, com fidelidade, o quanto afirmado no depoimento prestado na Delegacia de Polícia, dando conta do ocorrido na data dos fatos. Ambos descenderam a minúcias, retratando o fato como realmente passado.

Disseram que abordaram o réu e com ele encontraram 5 pinos contendo cocaína e, em sua casa, outros 65 pinos com cocaína.

Quanto às teses defensivas, nenhuma delas é capaz de afastar a responsabilidade do réu.

A alegação de ilicitude da prova, ao argumento de que não havia fundada suspeita para a busca pessoal, não encontra suporte no direito posto e nos fatos.

Com efeito, os policiais se ativeram a conceitos subjetivos e objetivos que detêm em razão do exercício da atividade policial ao longo dos anos. Estavam em um local onde impera o tráfico de drogas e a atitude do réu ao avistá-los despertou a fundada suspeita de que necessitavam para a realização da busca pessoal, que, inclusive, se mostrou exitosa.

O fato de um policial ter afirmado que o réu desviou o olhar e o outro policial ter dito que o réu mudou de direção não se mostra hábil a infirmar a prova.

Evidente que na narrativa dos fatos pelos policiais possa haver alguma contradição. Seria demais exigir deles, que realizam inúmeras prisões diariamente, a lembrança exata dos fatos que, geralmente, serão perguntados meses depois das ocorrências, sendo lúdica e até merecedora de encômios, a conduta do policial que colabora com a Justiça, visando à sua plena realização, na busca pela verdade real.

Por outro lado, o ingresso na residência foi devidamente autorizado, como bem disseram os policiais. Além disso, o próprio réu, na delegacia, afirmou que franqueou a eles a entrada (fls. 4), não se aferindo qualquer mácula na autorização fornecida pelo réu, nem mesmo a afirmada coação alegada pela Defesa, que não conta com qualquer indício que a corrobore.

Na linha das teses da Defesa, a busca pessoal resultaria inviabilizada em qualquer caso, sendo letra morta, assim como a busca domiciliar, mesmo autorizada pelo morador, em nenhuma circunstância seria válida.

Não há, assim, qualquer irregularidade, seja na busca pessoal, seja no ingresso no imóvel.

Acerca do tema, oportuno registrar recente decisão da Suprema Corte que evidencia a legalidade da conduta dos policiais:

"A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado (RHC 213852 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 30.5.2022)

Quanto às provas da traficância, essas são suficientes, diversamente do que afirma a Defesa.

Verifico, com a devida vênia, que é a versão apresentada pelo réu que não conta com

qualquer seguro elemento de prova. Contra ele há provas evidentes que consistem na afirmação dos policiais e nas drogas apreendidas em seu poder.

Como já afirmado, eventual divergência na oitiva dos policiais, em pontos circunstanciais, é completamente normal, não infirmando os fatos provados em seu conjunto.

Anoto, por outro lado, que a confissão informal de pessoas abordadas na rua com drogas é completamente normal e corriqueira, oportunidade em que não raras vezes apontam seus endereços e autorizam a busca nos imóveis.

A insinuação velada de que a droga foi “plantada”, da mesma forma, não encontra qualquer amparo nos elementos existentes nos autos, sobressaindo nessa alegação apenas o interesse em tentar se eximir da responsabilidade que lhe é atribuída.

Com efeito, não havia motivo algum para que os policiais o incriminassem com drogas, por puro casuismo.

Essa tese levantada pressuporia que os policiais seriam corruptos e que incriminariam qualquer pessoa escolhida ao léu, o que não se mostra razoável.

Não se vê, nesse ponto, qualquer motivo para que os policiais agissem dessa forma. A polícia está a serviço da justiça e, com exceção de alguns poucos casos – que sempre são repreendidos de forma severa – a quase que totalidade dos policiais é honesta e não se presta a delitos. A alegação busca somente livrar o réu de sua certa responsabilidade.

O que se verifica, mais uma vez, é uma tentativa desesperada de atribuir aos policiais, que atuam ao lado da lei, a responsabilidade que é do réu, desviado em sua conduta, valendo-se de meios ilícitos e ilegais para obter dinheiro fácil.

A propósito, a testemunha Edmilson relatou já ter abordado o réu em outras oportunidades, sem que com ele fosse encontrada droga, relat que vai ao encontro da alegação do réu de que já havia sido abordado pelos mesmos policiais que o detiveram em outras oportunidades, sem que nada de ilícito tenha sido encontrado com ele, evidenciando que não existe nenhum tipo de interesse por parte dos policiais em prejudicar o réu.

Por outro lado, se afigura evidente que o depoimento da mãe do réu deve ser recebido com natural reserva, pois tem pleno interesse na absolvição dele.

Assim, aceitar a versão defensiva seria fechar os olhos para uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total e completo desapego às normas genéricas da verdade e de bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.

Também não é o caso de se desclassificar o delito para a posse para uso próprio. Como se viu, a quantidade de droga demonstra que o réu é dado a traficância, não se compadecendo com o mero usuário.

Impõe-se, outrossim, afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4.º, da Lei 11.343/06.

De se anotar que a redução prevista na lei busca alcançar e tem por finalidade aquele pequeno traficante. É a ele que a lei visa a conceder a benesse, promovendo-lhe uma nova chance para que se ajuste ao meio social em que vive.

Registre-se, pelo que se depreende das provas colhidas, a despeito da primariedade, o réu, nos autos de número 1501150-96.2021, foi condenado (ainda sem trânsito em julgado). Contudo, confessou que naquela oportunidade estava traficando. Os fatos

se deram em 18.8.2021.

No caso presente, alguns meses depois, foi novamente preso em flagrante, o que evidencia seu intrínseco, profundo envolvimento com o tráfico a afastar a aplicação do benefício postulada.

Estabelecida a responsabilidade, passo à dosimetria da pena, com fundamento no artigo 68, do Código Penal, atento ao critério trifásico desenvolvido por Nélson Hungria e obediente à individualização da pena.

Na primeira fase impende observar a regra do artigo 42, da Lei 11.343/2006, pelo qual preponderam sobre o artigo 59 a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social da agente.

A qualidade da droga (cocaína) e quantidade em peso líquido – a despeito de relevante -, não pesa em desfavor do réu.

No que se refere à personalidade do agente - que no entender de Guilherme Nucci é aquela que está vinculada às qualidades morais, às distorções de caráter, à índole do sujeito, que são extraídos de sua forma habitual de ser, agir e reagir (in Individualização da pena, RT, 2005, p. 207) - se mostra negativa.

Isso porque resultou claro que o réu mentiu em Juízo quando alterou a versão dos fatos ocorridos, trazendo exposição falsa acerca de como se passaram os fatos. Além disso, na sua vã tentativa, afirma que os policiais cometeram crime - quando estes apenas cumprem seu papel -, tudo isso visando a uma injusta absolvição. Essa atitude demonstra a distorção de caráter e a ausência de senso moral por parte do réu, que se vale da mentira com o propósito de impor tumulto à instrução processual e, maliciosamente, induzir em erro o julgador, com afronta à dignidade da justiça.

Sobre a questão, oportuno ressaltar que ainda que seja o interrogatório um meio de defesa e de prova, evidente que o réu deva respeitar as limitações impostas pelas regras do processo, especialmente aquelas decorrentes da lealdade, da ética, da boa-fé, não se podendo esquecer que o processo é um instrumento para a realização da Justiça, dotado de uma série de formalidades que, em última ratio, são verdadeiras garantias para o réu, como também para a sociedade.

Ora, é forçoso reconhecer que o réu ao mentir deliberadamente extrapola os limites da autodefesa - que não é absoluta - demonstrando torpeza e deslealdade processual, expondo a risco a Justiça que pode, em razão de seu proceder, proferir decisão equivocada e, assim, injusta.

Afigura-se evidente que não se pode tolerar que o réu se valha de engodos, ardis e mentiras visando a escapar de uma justa condenação. O acusado que assim age, frauda a produção de provas e torna o processo uma chicana pessoal e egoísta, revelando sua personalidade dissimulada, amoral, o que justifica a elevação da pena.

Acerca do tema, pertinente o registro da lição de Andrey Borges de Mendonça (Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais, 2011, Método, p. 194): “Parece-nos, assim, que se o juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar - até porque para isto já há uma circunstância atenuante genérica -, mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e, perante um agente do Estado, possa mentir livremente, como se isto fosse algo normal e aceitável, como se entende atualmente”.

O entendimento acima explicitado, ainda que minoritário na jurisprudência, tem sido prestigiado em várias decisões judiciais, cabendo o registro, por todas, de parte do judicioso voto da lavra do Desembargador José Raul Gavião de Almeida, na

Apelação 00771651-20.2015, da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgada em 30 de novembro de 2017 :

"...Se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a verdade"

Ainda sobre o tema, se revela oportuno registrar parte do artigo " A mentira do réu como elemento relevante na dosagem da pena", da lavra do Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Cleber Pereira Defina, que de forma judiciosa analisou o tema:

"...assim como a confissão dos fatos denota aspecto louvável da personalidade do agente, pois atua com boa-fé e consciência social, o inverso também é verdadeiro: a mentira do agente sinaliza aspecto censurável de sua personalidade, pois atua com má-fé e franca ausência de consciência social, constituindo-se, portanto, em dado sensível quando da individualização da pena. O indivíduo que mente à autoridade só pretende beneficiar-se com a própria torpeza, conduz ao indesejável erro judiciário, prejudica o direito das vítimas e mina a justiça. Este cenário ratifica a deformação dos valores carregados pelo acusado pinoquista, repercutindo em necessidade ainda maior de reconstituição da tábua de valores socialmente almejada em relação ao acusado enganador. Ora, se é justo que a postura de lealdade do imputado deve surtir efeito no sentido de diminuir sua reprimenda, porque atrelada a condições favoráveis de sua personalidade, segue-se clarividente que há mesma justiça em extrair efeito no sentido de agravar a reprimenda do réu que ostenta péssima personalidade caracterizada pela insolência de mentir perante as autoridades que colheram sua versão dos fatos, especialmente quando a este acusado lhe foi garantido o direito ao silêncio. Aliás, onde o silêncio for útil, não se justifica a mentira. O mesmo Estado que garante ao processado o direito ao silêncio, a possibilidade de não se autoincriminar, que pode criar recompensas para este falar, como é o caso da atenuante da confissão e do acordo da delação premiada, também deve poder intensificar a reprimenda daquele que ousa falar com o exclusivo propósito de enganar e promover injustiça. O embuste, tanto quanto a lealdade, é vetor a moldar a pena justa, pois ambos dizem respeito à personalidade refletida do agente"http://www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/148/68).

Em suma, todo acusado tem o sagrado e inafastável direito ao silêncio, que decorre da garantia democrática de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere ou privilege against self incrimination); contudo, tal direito não pode admitir a interpretação que alguns lhe emprestam de tornar aceitável, ou pior, irrelevante, a conduta comissiva de mentir, que é vil, antiética e contrária aos valores mais mezinhos da sociedade, ao revés, deve o julgador, por ocasião da individualização da pena, caso constatado que o réu mentiu ao ser interrogado em juízo, fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo, amparado na personalidade negativa do acusado, pois evidente a ausência de senso moral, denotando índole desviada e personalidade distorcida, daquele que podendo se calar opta deliberadamente por mentir em juízo.

Não se pode olvidar, ainda, que o réu, desde a promulgação da Lei 11.719/2008, é interrogado após a colheita de todas as provas, inclusive depoimento das testemunhas, de forma que tem plena consciência das provas produzidas e da sua repercussão, mormente em razão da defesa técnica que o assiste, razão pela qual a sua opção pela mentira se mostra ainda mais censurável, cínica e abjeta, pois abre mão do direito ao silêncio, e até mesmo da atenuante da pena da confissão, para

tentar induzir em erro o juízo e assim ferir a dignidade da justiça.

A propósito, impende registrar, por relevante, que caso o julgador não aumente a pena do acusado mendaz, "estará incentivando o réu a sempre mentir, afinal, se sua mentira não lhe causa qualquer prejuízo, podendo, inclusive, livrá-lo de uma condenação justa, por que confessar um crime ou mesmo ficar em silêncio? Não punir o acusado mentiroso, aliás, viola o princípio da individualização da pena, pois equipara equivocadamente a situação do réu que fica em silêncio em seu interrogatório, com a do que mente descaradamente, em verdadeira afronta à dignidade da Justiça, pois tem o único propósito de induzir esta em erro, minando, assim, sua credibilidade perante a sociedade" ("A mentira do réu e a Dosimetria da Pena", artigo de autoria do Promotor de Justiça, Dr. André Wagner Melgaço Reis, publicado na rede mundial de computadores, no endereço <http://www.cartaforense.com.br/autor/andre-wagner-melgaco-reis/958>).

Nesse passo, cabe trazer recentíssima decisão proferida pelo voto do i. Desembargador Tetsuzo Namba:

"...demaís disso, se eles tinham a opção de confessar ou ficar em silêncio, no momento que se pronunciavam, suas palavras devem ser ponderadas, se mentem, como no caso dos autos, isso não pode ficar sem avaliação valorativa negativa, sob pena de deixar de lado quem, muitas vezes, colabora com a Justiça e diz a verdade, seria o patrocínio indevido da "não verdade", isso mostra o caráter de alguém, flagrado no cometimento de infração penal, não se arrepende, ao contrário, faz de tudo para se livrar das imputações... (TJSP – Apelação Criminal 0001611-29.2018.8.26.0625, 8.^a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 28.11.2019).

Cabe anotar que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento recente, por votação unânime, decidiu no mesmo sentido da tese que ora se adota, trazendo excertos de decisão proferida por este juízo como razão de decidir, como se infere dos autos da Apelação nº 0000129-67.2018.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Roberto Porto:

"Ademais, como bem destacou o Ministério Público a fl. 277 o fato de o réu ter mentido em Juízo, trazendo aos autos fatos absolutamente inverídicos, revela sua personalidade desvirtuada, devendo ser considerado no momento da exasperação da reprimenda. Aliás o Douto Magistrado bem fundamentou a exasperação da pena-base..."

No mesmo sentido já decidiu a Colenda 14^a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime nos autos da apelação nº 0000640-36.2016.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Walter da Silva:

"(...) Em relação ao delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03: Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a pena base foi bem fixada acima do mínimo legal, fundamentando o douto Magistrado na personalidade negativa do apelante, pois demonstrou perante o Juiz desonestidade e insinceridade, o que revelou a distorção de caráter, e assim a reprimenda foi tornada definitiva na ausência de outras causas modificadoras."

Ainda sobre a mentira do réu como circunstância desfavorável, com enfoque na personalidade desviada, em voto proferido pela 6.^a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, pela voz do ilustre relator Zorzi Rocha, assentou:

"Dessa forma, se o réu mentir em seu interrogatório, negando a prática do crime por ele cometido, ou explicando o crime ao apresentar uma versão fantasiosa do fato, tudo a fim de se obter uma injusta absolvição, justificado está o aumento de sua pena-base com fundamento na personalidade negativa. Afinal, a insinceridade e a desonestidade demonstradas perante o Juiz – como explanado no item 2 suso exposto –

revelam distorção de caráter e ausência de sendo moral por parte do Réu, que se utilizou da mentira – subterfúgio repugnado pela ética e pelo dever de lealdade – com nítido propósito de tumultuar a instrução processual e induzir em erro o julgador, afrontando, assim, a dignidade da Justiça” (TJSP – Apelação Criminal 0001317-32.2017.8.26.0618, j. 3.10.2019).

Não outra a conclusão a que chegou o ilustre Des. Ricardo Sale Júnior, chamando atenção para a correção do decísium que elevou a pena-base pelo fato de haver o réu mentido ao ser interrogado em juízo “fato que evidencia uma personalidade voltada para o crime” (TJSP – Apelação Criminal 0002205-19.2013.8.26.0625, 15.^a Câmara de Direito Criminal, j. em 8.8.2019).

No mesmo sentido o voto da lavra do ilustre Des. Tetsuo Namba, ao aduzir correta a sentença que reconheceu a mentira do réu como personalidade deturpada, justificando-se a elevação da pena na primeira fase da dosimetria. (TJSP – Apelação Criminal 0001091-27.2017.8.26.0618, 8.^a Câmara de Direito Criminal, j. em 5.12.2019).

Também em processo que teve trâmite por esta 3.^a Vara, em sede de apelação (Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625), a i. Desembargadora Ivana David, assentiu com a tese ora perfilada, nos termos seguintes, fazendo alusão, em parte, à decisão proferida nos autos do Processo Criminal nº 0003339-30.2014.8.26.0372, 1.^a Vara Judicial de Hortolândia - Juiz de Direito, Luis Mário Mori Domingues j. 21.01.2015.

“E escorreita a majoração praticada, uma vez que ao mentir em juízo, a acusada foi muito além do seu direito ao silêncio, mentindo para a Justiça, tentando se esquivar das consequências dos seus atos, porquanto, “nosso ordenamento jurídico, amparado por tratados internacionais e na linha de todos os demais sistemas penais do mundo garantem ao acusado o direito ao silêncio. Significa dizer que o réu, silenciando-se, não pode ser acusado com base nesse fundamento, isto é, ausente provas contra o réu, ele não pode ser condenado porque ficou em silêncio. Em momento algum o direito ao silêncio confunde-se com direito a mentira. O silêncio é uma conduta passiva, fundada no direito de não produção de prova contra si. A mentira é conduta ativa, é a produção de prova falsa em juízo”, demonstrando, com isso, além da má índole, que o crime não constituiu um episódio acidental em sua vida. (Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 10.12.2019).

No que respeita à culpabilidade, o que se vê é natural à espécie.

O réu é primário.

Acerca da conduta social do réu não há elementos para que se proceda à sua valoração.

Quanto aos motivos do crime e as circunstâncias, nada há de relevante.

O sujeito passivo do tráfico de drogas é a coletividade, titular do bem jurídico a saúde pública, não havendo, assim, falar-se em comportamento da vítima.

Diante da personalidade negativa, elevo a pena mínima cominada em 1/6 e fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

Na segunda fase, vislumbro a circunstância atenuante da menoridade relativa, de forma que torno a pena ao mínimo legal, não podendo levar a pena abaixo do mínimo em razão do disposto na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Não há, outrossim, circunstâncias agravantes, fixada a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da reprimenda, não há causas de diminuição ou aumento, mantida, assim, a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

O regime inicial para o crime apenado com reclusão será o fechado.

Trata-se de condenação pelo cometimento do delito de tráfico ilícito de drogas, crime que denota conduta absolutamente perniciosa à sociedade, sobretudo por contribuir com a disseminação da substância ilícita entre a população, fato que, por alcançar patamares insuportáveis, coloca em risco, inclusive, a tranquilidade social e a ordem pública, mormente por ser causa mediata de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza patrimonial. Além disso, o tráfico é equiparado a crimes hediondos e merece, desse modo, tratamento mais severo, sendo que a gravidade da conduta também exige maior rigor por parte do Estado. Outrossim, o réu foi preso e processado recentemente por idêntico crime de tráfico de drogas, tendo sido inclusive condenado em primeiro grau, estando o processo aguardando o julgamento do recurso, evidenciando sua periculosidade social.

Nos termos do artigo 49, §1.º, do Código Penal, o valor do dia multa será de 1/30 avos do salário mínimo praticado à época do delito, pois ausentes elementos para aferição da capacidade financeira do réu, devendo ser atualizado pelos índices de correção monetária da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde aquela data até o efetivo pagamento.

Incabível a substituição de pena, pois a medida seria insuficiente e ineficaz à reprovação do agente e à repreensão do delito. Ademais, levando-se em conta, mais uma vez, a gravidade in concreto do crime, insuficiente seria sua aplicação, com fundamento no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Incabível, outrossim, a suspensão da pena prevista no artigo 77, em razão da reprovabilidade e da perniciosidade da conduta da traficância, bem como por afrontar o espírito da Lei 11.343/06, que em seu artigo 44, veda a concessão de sursis.

Anote-se, ainda, que a despeito da Resolução n 5, do Senado Federal, que suspendeu a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", presente no §4.º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, a conversão e o sursis não se fazem adequados à prevenção e repressão do crime em espécie, pois, como já se decidiu, "os efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas, que acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam a postura indiferente adotada pelo agente com reação à saúde pública, o bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos, o que vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, qual seja, 'os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente'" (TJSP, apelação 0026205.40.2008.8.26.0405).

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois inexistente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência.

Mantenho a prisão cautelar, recomendando-se aquela em que se encontra.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que inexistente ilegalidade em vedar ao condenado recorrer em liberdade quando esteve preso cautelarmente durante toda instrução criminal, desde que permaneçam os motivos dessa segregação (STF, HC n. 89824/MS 1ª T. unânime Min. Carlos Ayres Britto DJe 28/8/2008; STF HC n. 114536/MG 2ª T. unânime Rel. Min. Ricardo Lewandowski DJe 4/12/2012; STJ, HC n. 222002/RJ 5ª T. unânime Rel. Min. Laurita Vaz DJe 11/10/2013).

No caso concreto, o réu permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo e o

retorno ao convívio social, neste momento, é inoportuno. Assim, para que a ordem pública permaneça acautelada, é necessária a manutenção do réu no cárcere.

O histórico criminal evidenciado indica que faz da prática de infrações penais meio de vida – foi condenado recentemente por crime idêntico, condenação que ainda não transitou em julgado – mostrando-se imprescindível acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça.

Sobre o tema, oportuno registrar recente decisão do Supremo Tribunal Federal:

"A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva" (HC 210820, AgR, relator André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 16.5.2022).

Nesse contexto, ainda persistem os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a segregação cautelar, agora mantida com base em um juízo de certeza da culpa.

Assim, presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, a teor do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, fica mantida a prisão (artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal), negando-se o direito de recorrer em liberdade.

Diante de tal quadro, verificada a necessidade da manutenção da custódia cautelar, resulta cumprido o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Não há dados suficientes para realização da detração da pena, razão pela qual deixa-se de cumprir o disposto no artigo 387, §2, do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução, que detém as informações necessárias, analisar oportunamente eventual direito do réu por conta do período que ele permaneceu preso cautelarmente, consoante determina o artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c". Nesse sentido: (HC 169.072/SP, relator Ministro Og Fernandes – 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 10.6.2010).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, de acordo com o artigo 804, do Código de Processo Penal.

Posto isso, acolho o pedido formulado na denúncia para condenar o réu Marcos Paulo Fernandes à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, iniciando-se o cumprimento em regime fechado, recomendando-o à prisão em que se encontra, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, condenando-o, outrossim, ao pagamento das custas no importe de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei estadual 11.608/03.

Após o trânsito em julgado deverá a Serventia levar a efeito as seguintes providências:

- a) intimar o réu para proceder ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal, assim como ao pagamento da taxa judiciária;
- b) oficiar ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) oficiar ao IIRGD comunicando a condenação do réu;
- d) expedir guia de execução penal.

R.P.I.

Taubaté, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA